

1500097-52.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... que o réu faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, pois, ainda que esteja respondendo a outro processo criminal por tráfico de drogas, os autos ainda não transitaram em julgado (fls. 46).

A propósito, o seguinte julgado da Corte Suprema: "o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500097-52.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500097-52.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2006827/2022 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22335657 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 102/22/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2006827 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Victor Andrew Bento Marcelino

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

VICTOR ANDREW BENTO MARCELINO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo o artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 244-B na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal), ambos com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, durante a pandemia causada pela covid-19, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente DOUGLAS KAUAN DA SILVA, para fins de tráfico, 39,7g de cocaína em pó, individualizado em 55 (cinquenta e cinco) invólucros, 33,3g de TETRAHIDROCANNABINOL, popularmente

conhecida como maconha, individualizado em 16 (dezesesseis) invólucros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 94/95) e apresentou defesa prévia (fls. 99/101). A denúncia foi recebida (fls. 105/106) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 128/129).

Durante a instrução criminal, o denunciado foi interrogado, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi reinquirido (fls. 143/144 - audiência virtual). Na fase de debates, o Ministério Público requer a parcial procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria do delito, contudo, pleiteia a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da lei nº 11.343/2006, com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (audiência virtual). A Defesa pugna pela absolvição do réu, ante a falta de provas, e, subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal (audiência virtual).

É o breve relato.

DECIDO

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 04/06), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fl. 15), laudo de constatação (fls. 30/36), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 134/136), bem como pela prova oral amealhada.

A autoria é certa.

VICTOR ANDREW negou a prática do crime. Contou que foi ao local para comprar drogas com o adolescente Douglas Kauan da Silva, ora traficante, e, quando saía da região, foi abordado pelos guardas municipais. Esclareceu que não conhecia Douglas e foi ao local por indicação. Afirmou que os guardas orientaram o adolescente a culpá-lo de ser o responsável pelo comércio das drogas, contudo os entorpecentes apreendidos pertenciam a Douglas e foram encontrados próximos do infrator, salientando que, no momento da abordagem, estava a sete metros de distância do menor. Às questões, afirmou que possui passagens pela Fundação Casa por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas e, após completar dezoito anos, passou a responder por outro delito de tráfico de drogas. Ao final, informou que é dependente químico, mas nunca foi internado, e que cursava o segundo ano do ensino médio (audiência virtual).

A testemunha Albérico relatou que a equipe realizava patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, ocasião em que avistaram dois indivíduos sentados na região. Disse que, ao se aproximarem, os dois tentaram se evadir, mas, como estavam próximos deles, conseguiram abordá-los. Informou que nada de ilícito foi localizado na busca pessoal, contudo, próximo de onde eles estavam sentados foi encontrada uma sacola contendo entorpecentes e dinheiro. Ao ser questionado, os abordados acusaram um ao outro de ser o proprietário da sacola. Esclareceu que não flagraram ato de venda de droga e que os sujeitos estavam sentados um ao lado do outro. Por fim, declarou que o adolescente já foi abordado outras vezes portando droga, todavia, nunca havia visto o acusado (audiência virtual).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Erik. O agente municipal, no entanto, alegou que não conhecia o réu e nem o adolescente apreendido (audiência virtual). Após ouvir as declarações prestadas pelas testemunhas, VICTOR ANDREW manteve a versão anteriormente ofertada (audiência virtual).

As provas são cabais e irrefutáveis em desfavor do denunciado.

O auto de exibição e apreensão e o laudo de exame químico-toxicológico comprovam que foram apreendidas na posse do réu, 39,7g de cocaína em pó, individualizado em 55 (cinquenta e cinco) invólucros, 33,3g de TETRAHIDROCANNAVINOL, popularmente conhecida como maconha, individualizado em 16 (dezesesseis) invólucros, além da quantia de R\$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais) (fls. 15 e 134/136). Consta dos autos que os guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina e visualizaram o denunciado acompanhado de um adolescente, sentados em local conhecido pela guarda municipal como ponto de tráfico de entorpecentes. Segundo as testemunhas, VICTOR ANDREW tentou se evadir, contudo foi abordado e nada de ilícito

foi encontrado na revista pessoal. Porém, ao retornarem ao local onde estavam sentados, localizaram uma sacola com entorpecentes e dinheiro. Embora os agentes municipais não tenham flagrado o réu em conduta típica do repasse de drogas a terceiros, relataram que foi encontrada uma sacola com as substâncias ilícitas e dinheiro exatamente no local onde ele estava posicionado antes de ser abordado.

Perante a autoridade policial e em juízo, o réu negou a prática do delito e informou que foi ao local comprar drogas do traficante Douglas Kauan da Silva que, por sua vez, segundo as testemunhas, afirmou que foi ao local adquirir entorpecentes com VICTOR ANDREW (fls. 10 e 109/114).

A versão do réu de que possuía apenas a intenção de comprar entorpecente no momento da abordagem, restou isolada. As testemunhas não deixaram dúvidas que denunciado estava sentado ao lado do adolescente e somente saiu do local após perceber a presença dos guarda municipais.

Não bastasse, nos autos do ato infracional, referida testemunha esclareceu que informalmente o adolescente Douglas Kauan confessou que estava ali para auxiliar o traficante VICTOR, como pode ser constatado na sentença do infrator, juntada a esses autos a fls. 139, sexto parágrafo.

Ademais, VICTOR ANDREW admitiu que já praticou ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas e, após completar a maioridade, foi preso em flagrante por tráfico de substâncias ilícitas. E se não bastasse, depois de quase um mês que lhe foi concedida a liberdade provisória, foi novamente preso em flagrante pelo mesmo crime (fl. 46).

Assim, demonstra que está inserido no mundo ilícito e sua versão tem a nítida intenção de ludibriar o Juízo, a fim de que seja considerado como mero usuário de drogas e não seja responsabilizado pela prática delitiva.

Anoto que não há qualquer dado que infirme as palavras dos guardas municipais que agiram de forma correta, conforme pode ser verificado nos procedimentos realizados na fase de inquérito. Ademais, os relatos dos responsáveis pela segurança são coerentes e não há notícias de que tenham motivos para incriminá-lo gratuitamente. O caso concreto autoriza o reconhecimento da circunstância agravante da calamidade pública (artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal), enfrentada pelo país, em decorrência da infecção em massa pela COVID-19.

Todavia, reconheço que o réu faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, pois, ainda que esteja respondendo a outro processo criminal por tráfico de drogas, os autos ainda não transitaram em julgado (fls. 46).

A propósito, o seguinte julgado da Corte Suprema: “o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que “A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recurso, sob pena de violação do artigo 5º, LIV, da Constituição Federal”. (RE 1.283.996 AgR Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020) .

Saliento, ainda, que os antecedentes infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes.

Para corroborar: “Como é cediço, ações penais em andamento, bem como atos infracionais, não se prestam a majorar a reprimenda, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos da Súmula n.444/STJ” (STJ, GC nº 394.526/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, C. 5Turma, julgado em 06/06/2017, g.n.).

No mais, reconheço a incidência da qualificadora do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, pois restou comprovado que o réu praticou o delito agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente, que à época dos fatos contava apenas com dezessete anos de idade (fls. 11/14 e 109/114), conforme julgado: “Não restando dúvidas de que o apelante, ao ser abordado pelos policiais, se encontrava em área local de traficância e na companhia de um menor, deve incidir a causa de aumento especial prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas” (HC 730263 DF 2022/0077826-9, Publicação 26/04/2022, Rel. Des. Ministro Olindo Menezes).

Assim, pelas circunstâncias do flagrante delito, depoimentos seguros das testemunhas, quantidade de droga encontrada com o réu, forma como foi embalada (apta à venda), a certeza é absoluta da destinação do entorpecente ao tráfico. Passo a dosar a pena.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

A princípio, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante do crime cometido em estado de calamidade pública, período em que comprovadamente as pessoas se encontram em total fragilidade, vulnerabilidade, e até mesmo incapacidade geradas em virtude da pandemia do Covid-19, acresço à reprimenda a fração de 1/6, a qual passará a ser de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase da dosagem da pena, reconheço a qualificadora do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, pois VICTOR ANDREW praticou o delito agindo em concurso e unidade de designios com pessoa que possuía 17 (dezesete) anos de idade, assim, acresço à reprimenda a fração de 1/6, a qual passará a ser de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Devido à prova de que o acusado faz jus à benesse prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 1/6 e a fixo, em definitivo, em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa. Ressalto que a diminuição se deu no mínimo, pois ficou demonstrado que se trata de acusado que comercializava cocaína, entorpecente que possui alto poder de dependência física e psíquica, sendo extremamente nocivo à saúde. Ademais, em menos de um mês da data dos fatos, o réu havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime, se valeu da concessão de liberdade provisória para continuar no mundo ilícito, a indicar que faz do tráfico de drogas seu estilo de vida.

Não há outras circunstâncias a serem consideradas, assim, torno a pena definitiva neste patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face do réu e CONDENO VICTOR ANDREW BENTO MARCELINO à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, o dia, por ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da lei nº 11.343/2006, com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Necessária a manutenção da custódia preventiva do réu, pois está envolvido com comércio ilícito de drogas. Ademais, é cediço que o tráfico ilícito de entorpecentes vem sendo cada vez mais repugnado pela sociedade, a qual está atemorizada com a avassaladora onda de violência que assola o país e que tem nas drogas sua mola propulsora. Não bastasse, tal crime é equiparado aos hediondos, sendo, a princípio, insuscetível de liberdade provisória, conforme preconiza o artigo 44, caput, da Lei 11.343/06. Assim, em face da gravidade do delito, que abala sobremaneira o conceito de ordem pública, faz-se necessária a permanência da prisão do acusado e a não substituição da pena carcerária por restritivas de direitos.

Sendo assim, o regime será o inicialmente fechado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Transitada em julgado a sentença, defiro a incineração da droga apreendida, nos termos requeridos pelo Ministério Público em fls. 79, salientando-se a necessidade de envio ao Juízo do auto de incineração.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em poder do acusado (fls. 15 e 85) em favor da União, mais especificamente, em benefício da FUNAD, acrescido de juros e correção monetária, conforme preceitua o art. 63, da Lei de Drogas. Anoto que o referido valor foi encontrado na posse do acusado no momento da abordagem, a concluir que é produto do tráfico de entorpecentes.

Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, uma vez que foi

defendido por advogada dativa, o que demonstra não possuir condições de suportá-las.
P.I.C.

Poá, 17 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA